Contraloría General de la República
División de Coordinación e Información Jurídica

Dictamen	**080720N15**				
Estado	-	**Nuevo**	SI	**Carácter**	NNN
NumDict	80720	**Fecha emisión**	09-10-2015		
Orígenes	CGR				

Referencias

206520/2015, 89027/2015, 89738/2015

Decretos y/o Resoluciones

-

Abogados

-

Destinatarios

Diputada Karla Rubilar Barahona

Texto

Sobre presuntas anomalías en la contratación directa de asesoría jurídica, para la defensa judicial del Servicio de Salud Arauco.

Acción

Aplica dictámenes 66505/2010, 46564/2011, 31356/2013, 68504/2011

Fuentes Legales

dto 140/2004 SALUD art/31, ley 19886 art/8 lt/c,
dto 250/2004 HACIE art/10 num/3, ley 19886 art/8 inc/fin,
dfl 1/2005 SALUD art/16, dfl 1/2005 SALUD art/22,
dfl 1/2005 SALUD art/23 lt/h, dfl 1/93 HACIE art/3 num/3

Descriptores

contraloría general de la república, facultades CGR, informes de auditoría, orgánica de la administración del estado, municipalidades, funciones y atribuciones municipales, contratos administrativos, contratos, contratos de servicios

Texto completo

N° 80.720 Fecha: 09-X-2015

Se han dirigido a esta Contraloría Regional, la señora Karla Rubilar Barahona, Diputada de la República, y el señor Luis Santibáñez Bastidas, consejero regional, solicitando investigar la legalidad de la contratación mediante trato directo del proveedor Servicios Jurídicos Sapiaín Martínez SpA, por la cantidad de $ 104.000.000, para patrocinar la defensa judicial del Servicio de Salud Arauco, SSA, ante la demanda civil interpuesta por la empresa SOCOVESA Ingeniería y Construcciones S.A., en contra del mencionado ente de salud, por incumplimiento de contrato. De igual forma, el Director del SSA, solicita revisar la mencionada operación.

Además, requieren indagar si el SSA solicitó formalmente al Consejo de Defensa del Estado, CDE, la representación en dicha causa, Rol C-225-2014, como asimismo, esclarecer la participación en ella, del profesional, abogado Patricio Villaseñor Canales.

Sobre el particular, cabe puntualizar de modo previo, que mediante resolución exenta N° 343, de 5 de febrero de 2009, se sancionó el texto del contrato de esa misma data, suscrito entre el SSA y la empresa Socovesa Ingeniería y Construcciones S.A., para la ejecución de las obras civiles en la reposición del. Hospital de Cañete, por un valor de $ 18.776.993.460, con un plazo de 630 días corridos, cuya convención, posteriormente, ha sido objeto de diversas modificaciones, en cuanto a su monto y vigencia.

En este contexto, el referido proveedor, el 26 de septiembre de 2014, deduce ante el Juzgado de Letras de Lebu, una demanda civil, aduciendo incumplimiento del contrato de que trata, en contra del SSA, Rol C-225-2014, caratulada "Socovesa Ingeniería Construcciones S.A., con Servicio de Salud de Arauco", la que fue notificada al demandado el 2 de octubre de esa misma anualidad.

Del análisis de los antecedentes tenidos a la vista y las validaciones efectuadas en terreno, se determinaron las observaciones que se exponen a continuación.

1. Sobre la contratación directa del proveedor.

1.1 Legalidad del procedimiento de compra.

En primer término, el artículo 31 del decreto N° 140, de 2004, del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento Orgánico de los Servicios de Salud, prescribe en lo que interesa, que las adquisiciones de bienes muebles y de servicios que se requieran para el desarrollo de sus funciones, deberán efectuarse con sujeción a la ley N° 19.886, de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y demás normas legales aplicables a la materia.

En este contexto, mediante la resolución exenta N° 3.396, de 10 de noviembre de 2014, la autoridad calificó la urgencia de la contratación del servicio profesional de un abogado o de un estudio jurídico con especialidad en derecho civil, para que asumiera la defensa legal del SSA en la demanda Rol C-225-2014, ya mencionada, autorizando en el mismo acto, el trato o contratación directa del proveedor Servicios Jurídicos Sapiaín Martínez SpA, por la cantidad de $ 104.000.000, para el patrocinio en la causa descrita.

Cabe agregar, que para la dictación del acto administrativo reseñado, se invocó como fundamento legal, lo dispuesto en el artículo 8°, letra c), de la ley N° 19.886, ya referida, en relación con el numeral tercero del artículo 10° del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el reglamento de dicho texto normativo, disposiciones conforme a las cuales, es posible acudir a esa modalidad de contratación en casos de emergencia, urgencia o imprevisto, calificados mediante un acto administrativo fundado del jefe superior de la entidad contratante.

Efectuada las precisiones que anteceden, es menester consignar que esta Entidad de Control ha manifestado a través de los dictámenes Nos 66.505, de 2010, y 46.564, de 2011, que cualquiera que sea la causal en que se sustente un eventual trato directo, al momento de invocarla, no basta la sola referencia a las disposiciones legales y reglamentarias que lo fundamenten, sino que, dado el carácter excepcional de esta modalidad, se requiere una demostración efectiva y documentada de los motivos que justifican su procedencia, debiendo acreditarse de manera suficiente la concurrencia simultánea de todos los elementos que configuran las hipótesis contempladas en la normativa cuya aplicación se pretende.

En dicho ámbito, para recurrir a ese procedimiento de compra, la superioridad tuvo a la vista, entre otros antecedentes, la referida demanda civil por aproximadamente $ 5.000.000.000, notificada el 2 de octubre de 2014, con plazos perentorios para contestar; el informe del abogado contratado a honorarios por el SSA, don Patricio Villaseñor Canales, de fecha 20 de octubre de ese mismo año, que señala que los profesionales del Departamento de Asesoría Jurídica no se encuentran en condiciones de asumir por si solos la causa de que se trata, en atención a su reciente reestructuración, además de mantener una importante recarga laboral que les impediría tener dedicación exclusiva en la contienda que se analiza; el memorándum N° 172, de 10 de noviembre de 2014, del Jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica del SSA, quien indica que se desempeña en dicho cargo a contar del 8 de septiembre de 2014, que la cuantía de lo disputado y la naturaleza de la contienda hace necesario contar con servicios profesionales especializados, añadiendo, que no ha tramitado litigios de esa envergadura, todo lo cual, impide que el departamento que dirige se encuentre en condiciones de hacer frente a la demanda mencionada.

Sobre el particular, es menester indicar que, en concordancia con la jurisprudencia administrativa de este origen, contenida en el dictamen N° 31.356, de 2013, las circunstancias que hagan procedente la referida modalidad de contratación deben concurrir al momento de dictarse el respectivo acto administrativo aprobatorio y deben encontrarse suficientemente fundamentadas, lo que acontece en la especie.

En virtud de los antecedentes tenidos a la vista e indagaciones efectuadas en terreno, no se advierte irregularidad en el procedimiento de contratación utilizado, toda vez que el Servicio de Salud de Arauco recurrió a la modalidad de adquisición en análisis con sujeción a la normativa correspondiente y en cumplimiento de los requisitos de fundamentación y acreditación efectiva y documentada de las razones que motivaron la procedencia de la causal.

1.2 Sobre solicitud de cotizaciones.

El artículo 8, inciso final, de la ley N° 19.886, señala en lo que interesa, que siempre que se contrate por trato o contratación directa se requerirá un mínimo de tres cotizaciones previas, salvo que concurran, entre otras, la causal, de la letra c) de este articulado, invocada en el caso en estudio.

Sin perjuicio de lo anterior, la autoridad del SSA mediante resolución exenta N ° 3.370, de 3 de noviembre de 2014, aprobó los términos de referencias para la contratación de los servicios de un abogado o equipo de abogados, en cuyo texto se establecen los requerimientos técnicos, procedimiento de

presentación de ofertas, comisión de evaluación y criterios de selección, entre otros.

Enseguida, el Jefe del Departamento de Asesoría Jurídica de! SSA, don Aldo Molina Barra, invitó, en esa misma data, a través de correos electrónicos, a tres representantes de estudios jurídicos, a saber: Ramón Domínguez Águila, Remberto Valdés Hueche e Ignacio Sapiaín Martínez, para que presentaran su cotización, en un plazo que no excediera del 6 de noviembre de 2014, antes de las 16:00 horas, recibiéndose en aquella data y hora, la propuesta de los dos últimos profesionales.

En este contexto, el 7 de noviembre de igual anualidad, la comisión designada al efecto evacuó el informe de evaluación de los oferentes, proponiendo al Director del SSA, conferir la contratación de que se trata, al profesional Ignacio Sapiaín Martínez, representante de la sociedad Servicios Jurídicos Sapiaín Martínez SpA, para lo cual procedió a dictar el acto administrativo que autoriza la contratación directa ya analizada.

En consideración a lo señalado, no se determinaron observaciones que formular.

1.3 Sobre el contrato, caución del mismo y pago de prestaciones.

Mediante resolución exenta N° 3.982, de 20 de diciembre de 2014, se aprobó el texto del contrato, de fecha 17 de noviembre de esa misma anualidad, suscrito entre el SSA y la empresa Servicios Jurídicos Sapiaín Martínez SpA, para patrocinar y representar los intereses del SSA en la defensa de la causa Rol N° C-225-2014, del Juzgado de Letras y Garantía de Lebu, con una vigencia desde la contestación de la demanda, esto es, la misma data del contrato, hasta que la sentencia quede firme o ejecutoriada, por un monto de $ 104.000.000, impuesto incluido, pagaderos en tres cuotas, a saber, $ 34.666.666, por la presentación de la contestación de la demanda; $ 34.666.667, al citarse a las partes a oír sentencia y $ 34.666.667, cuando la sentencia quede firme y ejecutoriada o se ponga término definitivo a la litis por medio de un equivalente jurisdiccional.

Asimismo, se comprobó que la citada empresa tomó la boleta de garantía N° 181527, de 29 de diciembre de 2014, a favor del SSA, para caucionar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato, ascendente a $ 5.200.000, equivalente al 5% del valor total de éste.

Se constató que, al 13 de agosto de 2015, el SSA, pagó la primera cuota contemplada en las cláusulas quinta y sexta del contrato respectivo, mediante comprobante de egreso N° 29, de 02 de febrero de 2015, por la cantidad de $ 34.666.666, a través de cheque N° 2551159, de 27 de enero de esa misma anualidad.
En consecuencia, no existen observaciones que formular en la especie.

1.4 Sobre publicación de resolución fundada en el sistema de información de compras públicas.

Se verificó que el SSA, emitió la orden de compra electrónica N° 652-970-SE14, de 10 de noviembre de 2014, por la cantidad de $ 104.000.000, a través del portal www.mercadopublico.cl.

Luego, el 11 de noviembre de esa misma anualidad, elevó a dicha plataforma de adquisiciones, la resolución exenta N° 3.396, de 2014, que califica de urgencia la contratación del servicio profesional jurídico y que aprueba la contratación directa pertinente, dando cumplimiento con ello, al artículo 8°, de la ley N° 19.886, que prescribe en lo que interesa, que las resoluciones fundadas que autoricen la procedencia de la materia de que se trata, deberán publicarse en el sitio web www.mercadopublico.cl, a más tardar dentro de las 24 horas de dictadas, lo que aconteció en el caso en análisis.

A mayor abundamiento, el 18 de marzo de 2015, el SSA también publicó en dicho portal, la resolución exenta N° 3.982, de 2014, que aprueba el contrato ya analizado y el texto del mismo.

2. Sobre solicitud de patrocinio al Consejo de Defensa del Estado.

En relación a esta materia, se comprobó la ausencia de evidencia física o electrónica, que permita verificar la existencia de algún tipo de requerimiento formal efectuado por el SSA, ante la Abogada Procuradora Fiscal de Concepción del Consejo de Defensa del Estado, CDE, para representar al servicio en la demanda en cuestión.

El artículo 16, del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N ° 2.763, de 1979, y de las leyes Nos 18.933 y 18.469, prescribe en lo que interesa, que los servicios de salud serán organismos estatales, funcionalmente descentralizados, dotados de personalidad jurídica y patrimonio propio para la realización de sus acciones.

Enseguida, el artículo 22 del mismo texto legal, señala que el director será el jefe superior del servicio y tendrá su representación judicial y extrajudicial, luego, el artículo 23, letra h), de la misma preceptiva, dispone en lo que importa, que tendrá entre otras atribuciones, transigir respecto de derechos, acciones y obligaciones, sean contractuales o extracontractuales.

Por su parte, el numeral 3, del artículo 3° del decreto con fuerza de ley N° 1, de 1993, del Ministerio de Hacienda, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Orgánica del Consejo de Defensa del Estado, preceptúa que es función de ese organismo: "La defensa en los juicios en que tengan algún interés los servicios de la administración descentralizada del Estado o las entidades privadas en que el Estado tenga aporte o participación mayoritarios, siempre que el respectivo servicio jurídico no esté en condiciones de asumir convenientemente tal función, circunstancias que en cada caso calificará el Consejo".

Como se puede advertir, de la normativa reseñada, el CDE, en el evento de haber tomado conocimiento de la acción legal en análisis, tenía la facultad de evaluar la situación en que se encontraba el SSA para asumir su defensa judicial con sus propios medios o de lo contrario representarlo en dicha causa, de conformidad a lo establecido en el numeral 3, del artículo 3° del decreto con fuerza de ley N° 1, de 1993, del Ministerio de Hacienda.

No obstante lo expresado, la decisión del director en orden a contratar directamente la asesoría jurídica externa de que se trata, corresponde a una

cuestión de mérito, oportunidad y conveniencia, sobre la cual no compete a este Organismo de Control emitir un pronunciamiento.

3. Sobre la contratación del profesional Patricio Villaseñor Canales.

A través de la relación de servicio suscrita por el Subdirector de Gestión y Desarrollo de las Personas del SSA, don David Nova Chávez, informa que don Patricio Villaseñor Canales se ha desempeñado por diez años en esa dirección, según el siguiente detalle.

RESOLUCIÓN EXENTA		CALIDAD JURÍDICA DE CONTRATACIÓN	GRADO	ESCALAFÓN	PERÍODO	
N°	FECHA				DESDE	HASTA
69	15-02-02	Designación titular	4	Directivo	13-02-02	23-11-05
154	24-11-05	Suplencia	4		24-11-05	28-02-06
10	27-01-06	Designación titular	4		01-03-06	28-02-09
57	19-03-09	Designación titular	4		01-03-09	01-03-12

Fuente: Certificado N° 15, del Subdirector de Gestión y Desarrollo de las Personas, don David Nova
Chávez, de fecha 11 de agosto de 2015.

Luego, mediante las resoluciones exentas que se indican en el cuadro que sigue, dicho servidor ha sido contratado en calidad de honorarios en la dirección del SSA, para desempeñar las funciones que allí se describen.

RESOLUCIÓN EXENTA		PERÍODO		FUNCIONES
N°	FECHA	DESDE	HASTA	
1.962	05-06-14	28-04-14	31-12-14	Asesorar jurídicamente a la Dirección del SSA en todo lo relacionado con proyectos de obras civiles, particularmente en el proyecto denominado "Contrato de Ejecución Obras Civiles Reposición Hospital de Cañete".
				Asesorar a la Dirección del SSA en las presentaciones ante la Contraloría General de la República.
				Redacción de distintos tipos de contratos y resoluciones.
				Representación del SSA en

				mediaciones sobre asunto de salud.
984	07-05-14	01-01-15	31-12-15	Patrocinio, poder y defensa en causas judiciales vinculadas al servicio, originadas por acciones judiciales de distinto tipo.
				Representación y defensa en asuntos contencioso administrativos con distintos servicios públicos.
				Elaboración de informes jurídicos dirigidos a la Contraloría General de la República y a otros servicios públicos.
				Asesoría jurídica y representación del servicio en proyectos de obras civiles, especialmente en la iniciativa de inversión denominada "Contrato de Ejecución Obras Civiles Reposición Hospital de Cañete" y la causa rol C-225-2014, del Juzgado de Letras de Lebu.

Fuente: Resoluciones exentas antes individualizadas.

Efectuada las precisiones que anteceden, se verificó lo siguiente:

3.1 Sobre el rol del abogado señor Patricio Villaseñor Canales en la causa analizada.

En virtud a los contratos a honorarios de prestación de servicios mencionados precedentemente, mediante los cuales se le asignan al señor Villaseñor Canales, entre otras funciones, la asesoría jurídica y representación del servicio en proyectos de obras civiles, particularmente con la iniciativa de inversión denominada "Contrato de Ejecución Obras Civiles Reposición Hospital de Cañete", le ha correspondido la participación en dicho litigio.

En este ámbito, el 16 de octubre de 2014, ante el Notario Público y Conservador de Minas de Concepción, señor Manuel Córdova Navarrete, el Director del SSA, le confiere un mandato judicial a don Patricio Villaseñor Canales, para que lo represente ante cualquier tribunal ordinario especial o arbitral de la República y/o Ministerio Público, en cualquier clase de asuntos civiles, criminales, laborales y administrativos que se promuevan o susciten, se encuentren pendientes o se originen en el futuro, sea en calidad de demandado o demandante.

Así las cosas, el 17 de octubre de 2014, dicho profesional, opuso una excepción dilatoria en causa Rol C-225-2014, del Juzgado de Letras y Garantía de Lebu, para que luego, don Ignacio Sapiaín Martínez respondiera a la demanda, lo que aconteció el 18 de noviembre de 2014.

No obstante lo anterior, de acuerdo a las indagaciones efectuadas y a lo manifestado por el Director del SSA, el señor Villaseñor Canales, en la actualidad, es el encargado de realizar las respectivas coordinaciones y de proporcionar los antecedentes necesarios que requiera la defensa contratada por el servicio, no advirtiéndose objeciones que formular en tal sentido.

3.2 Sobre presunto sumario administrativo que se habría instruido contra el señor Patricio Villaseñor Canales.

Referente a este asunto, cabe puntualizar de modo previo, que esta Entidad de Control mediante el dictamen N° 68.504, de 2011, al que alude la diputada señora Rubilar Barahona, se pronunció sobre una presentación efectuada por el señor Villaseñor Canales, respecto de diversas materias, entre ellas, la existencia de acoso laboral en su contra, por el cambio de funciones efectuado por la superioridad del SSA de la época.

En dicho contexto, el oficio, en su parte pertinente, plantea en síntesis, que si bien el referido servicio, señaló que uno de los cambios de funciones que afectaron a don Patricio Villaseñor, se debió a la pérdida de confianza de la autoridad respectiva, atendida su eventual participación en un hecho irregular, dicho organismo público, a quien compete la potestad disciplinaria respecto del personal que en él labora, no inició el correspondiente sumario administrativo, a fin de determinar la efectividad de los hechos aducidos y las responsabilidades que fueren del caso, cuestión que la directora de ese entonces debió analizar.

Precisado lo anterior, conforme a los antecedentes tenidos a la vista y las verificaciones efectuadas, se constató, en el Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado, SIAPER, de la Contraloría General de la República, la inexistencia de un proceso disciplinario ordenado por la autoridad del SSA, en el año 2011 y 2012, en contra del señor Villaseñor Canales, en virtud de la situación expresada.

A mayor abundamiento, de acuerdo a lo certificado por el Subdirector de Gestión y Desarrollo de las Personas del SSA, señor David Nova Chávez, con fecha 4 de agosto de 2015, en los registros de la hoja de vida funcionaria del señor Villaseñor Canales no figuran medidas disciplinarias en el período 2011 y 2012, año este último, en el cual dejó de desempeñarse como directivo de ese organismo de salud.

En consecuencia, no se advierten observaciones que formular en este sentido.

Transcríbase al Director del Servicio de Salud Arauco y a don Luis Santibáñez Bastidas, Consejero Regional del Bío-Bío.

Saluda atentamente a Ud.

Patricia Arriagada Villouta
Contralor General de la República
Subrogante

Glosario			
Dictamen	Código que identifica al documento jurídico.	**Nuevo**	Indica si el documento es nuevo o no.
Estado	Indica el estados del dictamen: **Guión** (si no ha habido pronunciamiento posterior) **Reactivado** (si ha sido aplicado o confirmado) **Alterado** (si ha sido aclarado, complementado, reconsiderado o reconsiderado parcialmente)	**NumDict**	Indica el número con que se identifica el dictamen.

Caracter	Contiene el carácter de la disposición legal o reglamentaria (NNN: sin connotación especial, BIS: de igual numeración, RES: reservado)	**Fecha emisión**	Indica la fecha de emisión del dictamen.
Origen	Corresponde a la sigla de la o las Divisiones de la Contraloria emisora del dictamen.	**Abogados**	Indica las iniciales del abogado informante.
Destinatarios	Nombre de la persona o autoridad a la que se dirige el documento.	**Texto**	Contiene un extracto del dictamen.
Fuentes legales	Contiene las disposiciones legales y reglamentarias asociadas con el dictamen.	**Descriptores**	Términos relevantes y siglas de organismos pertinentes.
Acción	Indica todas las acciones que el dictamen ejerce sobre otros anteriores.	**Texto completo**	Contiene el texto completo del dictamen.